

1500812-35.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME DE MERA CONDUTA. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GUARDA MUNICIPAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA. ART. 301 DO CPP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos delitos de mera conduta, aí incluídos o tráfico e a guarda de substância entorpecente, não é necessário resultado decorrente da ação ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Tatuí-SP - cep 18278-440

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500812-35.2022.8.26.0571 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500812-35.2022.8.26.0571

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159265/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25510464 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2159265 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADEMILSON ALBERT TEODORO BORGES DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Vistos.

Os réus ADEMILSON ALBERT TEODORO BORGES DOS SANTOS e JEDEDIAS SILVA DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 33, caput, e no art. 35, caput, ambos c.c. art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, eis que: 1) no dia 10 de junho de 2022, nesta cidade e Comarca de Tatuí, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas; e 2) no dia 10 de junho de 2022, por volta das 15h45, na Rua Lázaro Phols, nº 312 - Jardim Rosa Garcia, nesta cidade e Comarca de Tatuí, previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de desígnios, identidade de propósitos, traziam consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 1 porção de cocaína, com peso bruto aproximado de 0,6 gramas, 1 porção de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 1,44 gramas, 1 porção de cocaína, com peso bruto aproximado de 0,54

gramas, e 14 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 20,04 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo consta da exordial, na data dos fatos, os acusados se dedicavam ao tráfico ilícito e, para tanto, permaneciam juntos no local da abordagem aguardando usuários para promover a venda oportuna.

Guardas Civis Municipais estavam em serviço quando receberam informação de um popular dando conta de que "dois indivíduos" estavam vendendo drogas no "pasto" da Rua Lázaro Phols, informando o nome de um deles, JEDEDIAS, que estava de camiseta amarela, bem como descrevendo as vestes do comparsa, que vestia uma camiseta vermelha.

Diante disso, os Guardas se deslocaram para o endereço indicado e, lá chegando, avistaram os acusados - cujas vestes correspondiam àquelas descritas na delação - que estavam juntos embaixo de uma árvore e deliberaram pela abordagem. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos apresentaram atitude suspeita e tentaram deixar o local rapidamente.

Durante a tentativa de evasão, JEDEDIAS jogou um pacote de drogas no chão e, em seguida, ambos foram abordados pelos Guardas Municipais.

Assim é que, em revista pessoal, os Guardas encontraram 1 "pino" de cocaína dentro da cueca de JEDEDIAS, bem como a importância de R\$ 20,00 em espécie, valor angariado com a venda de drogas que ele promovia naquele local, de forma associada com o comparsa. Com ADEMILSON, os Guardas localizaram 1 porção de "maconha" e 1 "pino" de cocaína, drogas que lhe pertenciam e estavam destinadas à venda.

Dando continuidade às diligências, verificando o que JEDEDIAS havia dispensado, os Guardas encontraram um maço de cigarro contendo 14 porções de "maconha", individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, drogas que pertenciam aos denunciados e estavam destinadas ao comércio ilícito, que eles praticavam de forma associada no local.

Os réus foram notificados (fls. 113 e 116) e apresentaram Defesas Preliminares (fls. 117 e 118/128). Assim, por decisão proferida no dia 23 de agosto de 2022, foi recebida a Denúncia (fls. 130/134). Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas (fls. 166 e 169/170) e, ao final, os acusados foram interrogados (fls. 167/168), tudo gravado em audiovisual.

Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação dos acusados nos termos da exordial (fls. 164/165 e 192). Enquanto a Defesa Técnica, ao revés, pugnou pela absolvição dos réus, sustentando, em preliminar, nulidade de todas as provas, em virtude de derivarem de diligência efetuada por agentes incompetentes, bem como, no mérito, postularam pela absolvição dos réus, alegando, em apertada síntese, insuficiência probatória e, subsidiariamente, em caso de condenação, pela aplicação de todos os benefícios legais cabíveis a incidir em fase de dosimetria da pena e fixação do regime prisional inicial (fls. 164/165, 196 e 200/219).

Folha de antecedentes a fls. 40/41 e 44/46, bem como Certidões a fls. 42/43 e 47/49.

É o relatório do necessário.

Fundamento e Decido.

Preliminarmente, faz-se necessário salientar que operação levada a cabo pelos agentes públicos em comento atendeu aos requisitos legais, não violando preceito constitucional ou abrigado em Lei.

Ora, no exercício de suas atribuições conferidas por lei ordinária (art. 5º, II, da Lei nº 13.022/2014), a qual regulamentou a competência atribuída em nossa Carta Magna a esta corporação (art. 144, § 8º, da CF), visualizaram os réus, como se verá pelo teor da prova adiante, em atitude suspeita. E, em abordagem policial, encontraram drogas com ambos.

Presente, pois, o estado de flagrância delitiva, a atuação de "qualquer pessoa do povo" seria legal, de acordo com a previsão legal insculpida no art. 301 do Código de Processo Penal. E, se qualquer do povo poderia agir, com muito mais razão é possível se legitimar a prisão em flagrante efetuada pelos guardas civis municipais.

E, por tal razão, não há óbices para a ação dos guardas civis municipais.

Neste sentido, coleciono o seguinte julgado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME DE MERA CONDUTA. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GUARDA MUNICIPAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA. ART. 301 DO CPP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos delitos de mera conduta, aí incluídos o tráfico e a guarda de substância entorpecente, não é necessário resultado decorrente da ação ou omissão, bastando a simples conduta para a constituição do elemento material da figura típica penal, o que afasta a dúvida sobre o estado de flagrância delitiva do recorrente. 2. Dessa forma, à luz do art. 301 do CPP, "qualquer do povo" poderia ter efetuado sua prisão em flagrante, aí incluídos os agentes públicos da guarda municipal. 3. Afastada qualquer ilegalidade na custódia provisória decorrente de flagrante delito, afastado está o seu relaxamento. 4. Recurso a que se nega provimento. (STJ - RHC: 17645 SP 2005/0066036-6, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 06/09/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 26/09/2005 p. 408) (grifos aditados)

Superada a questão preliminar, passo ao exame da matéria meritória.

Pois bem, o pedido ministerial comporta parcial procedência, absolvendo-se os réus da imputação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme passo a expor.

É certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a persistência delitiva: "Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 10, e 34 desta Lei:" (grifos aditados)

No entanto, para se que não se confunda o mero concurso de pessoas – de que trata o art. 29 do Código Penal – com o delito de associação, estabeleceu-se o entendimento jurisprudencial e doutrinário que, para a caracterização do crime em comento, é imperioso que o dolo dos agentes que agiram em conluio projete-se por mais de um fato criminoso, ou seja, que pretendam exercer a narcotraficância em caráter permanente, estável e duradouro, denotando vínculo associativo e não mero concurso eventual.

Neste sentido, coleciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) 1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes. (...)" (STJ - HC: 214660 SP 2011/0178723-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2013)

Além disto, coleciono também o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"(...) Associação para o tráfico - Absolvição - Admissibilidade - O artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, não pode ser considerado um mero concurso de agentes, sendo necessário, para sua caracterização, a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de associar-se seja distinta da vontade da prática do crime visado (...)" (TJ-SP - APL: 00128516320108260344 SP 0012851-63.2010.8.26.0344, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/04/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2014)

Em idêntica lógica, assevera Guilherme de Souza Nucci que: "(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico (...)" (Nucci, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 1, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed, p. 337, item 103)

Assim, observando a premissa estabelecida e examinando o conjunto probatório amealhado nos autos, noto que, embora haja comprovação de que os acusados exerciam o tráfico de entorpecentes, inexistem provas suficientes de que praticavam ou

pretendiam perpetrar a narcotraficância em caráter permanente. Isto porque não houve prévia investigação policial, onde fosse possível verificar que o tráfico não seria exercido pontualmente, tampouco foram localizados instrumentos de preparação ou anotações de contabilidade, revelando o caráter não episódico da traficância.

Portanto, diante da ausência de provas em relação ao animus associativo entre os réus, imperiosa a absolvição deles no que se refere à imputação de ofensa ao art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

E mais, embora conste da capitulação da inicial acusatória a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, não houve qualquer comprovação de envolvimento de adolescente na prática criminosa, suporte fática indispensável a incidência da norma legal em questão.

Consequentemente, deve ser afastada a incidência também da majorante acima apontada.

No mais, a pretensão acusatória merece ser acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 34/37), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), pelo auto de constatação preliminar (fls. 10/11), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 102/104), pelo laudo pericial (fls. 177/187) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida.

A autoria é igualmente evidente. Vejamos:

O réu ADEMILSON, em solo policial (fls. 04), afirmou que comprou algumas "buxas de maconha" e pino de um desconhecido. Afirmou que acabou colocando as drogas nesse maço de cigarro. Não sabe de quem comprou as drogas, mas não é o corréu JEDEDIAS. Pagou pelo valor de R\$ 140,00 pelas drogas. Para não ter que ficar indo na "boca" várias vezes, resolveu comprar essa quantia maior. É usuário desde os 13 anos. Em juízo, disse que não estava vendendo droga. É usuário. Comprou umas buchas e um pino de cocaína. Já havia usado e comprou varias porções para não ter que voltar na biqueira. Quando os guardas chegaram estava sentado no meio do pasto sentado numa pedra, vendo a molecada jogar futebol. Tinha chegado e cumprimentado Jededias e ficaram sentados nesta pedra conversando. Chamou Jededias para fumar e quando estavam descendo foram abordados. Não dispensou a droga, deixou no mato, para não ficar andando com aquela quantidade. Quando foram abordados não estavam com esse maço de cigarro. Não compraram a droga da mesma pessoa. Conhece Jededias da Vila, encostava ali e ficou conhecendo ele. Na época dos fatos estava trabalhando na Zanqueta. Pagou R\$140,00 pela droga. Ganhava R\$1440,00 depois tinha uns descontos. Já conhecia os guardas municipais. Estava na viatura quando foram até a casa de Jededias e não sabe o motivo pelo qual foram lá. Nunca foi processado. Tem 19 anos. Perguntas da acusação - comprou 14 buchas de maconha e já tinha uma bucha de maconha e uma de cocaína. Deixou no mato as 14 buchas e ia descer para fumar e depois pegaria novamente. Quando chegou ao local Jededias já estava ali sentado na pedra, sozinho. Depois que saiu da pedra, deu uma volta, comprou a maconha, escondeu a droga e voltou para pedra. Iriam usar a droga num campinho de futebol que fica mais embaixo. Convidou Jededias porque sabia que ele era usuário de maconha, já usaram juntos. Próximo ao local há um bar que vende seda solta para enrolar a maconha. Perguntas para defesa - sabia que Jededias fumava maconha e o chamou para fumar. É usuário há 06 anos. Quando compra em maior quantidade traz para usar em casa. Essa pedra fica na lateral esquerda do gol, no campinho. É uma pedra embutida no chão. Precisa entrar no campo para chegar na pedra. Tem uma árvore grande que faz a sombra e varias pessoas ficam no local, há futebol e vira um local de lazer. Costuma comprar entorpecentes no local pois é perto de sua casa. Já viu usuários de crack no local, mas ele não faz uso ali, pois pega e usa em casa, pois trabalha.

De outro lado, o acusado JEDEDIAS, em solo policial (fls. 07), afirmou que, na data

dos fatos, não estava vendendo. Alegou que estava no pasto quando foi abordado pelos guardas e que não jogou nada. Estava somente com um pino que comprou pois é usuário. Em juízo, disse que tinha trinta reais e foi ao local comprar um pino. Quando foi abordado encontraram com ele um pino e ficou com R\$20,00. Logo em seguida foi abordado. Não estava junto com Ademilson. Já conhecia esses guardas, que já o abordaram e disseram que ele seria preso. A maconha era de Ademilson, pois escutou ele contar isso na delegacia. Comprou o entorpecente na viela. Não viu Ademilson dispensar nada, pois ele estava atrás dele, descendo com Gabriel. Os agentes públicos inventaram isso com intenção de prejudica-lo. Já foi preso por tráfico. Ficou na viatura quando os réus foram até sua casa, sendo que estava com o RG e o cartão do mercado. As vezes entrega lanche que sua mãe fazia. É solteiro. Tem 21 anos. Quando foi abordado estava andando lado a lado com Gabriel e Adenilson estava bem atrás, na outra esquina, ele estava andando também. Não estavam na árvore. Seu celular foi apreendido. Acha que Ademilson também estava com o celular. Perguntas da defesa – no ano passado foi abordado e preso pelo mesmo GCM ouvido nestes autos. É usuário de pó e maconha, há desde os 13 anos de um e 15 do outro. O local dos fatos é um campo de futebol. Esse local é um pouco longe de sua casa e costuma comprar a cocaína ali, depois vai para casa ou para o bar jogar bilhar. Na hora já reconheceu o GCM Fernando e ele assim que o viu já disse que ele estava preso. Do local dos fatos foram até sua casa e ele chegou entrando e depois que chamou sua mãe. Sua casa tem portão, mas sua mãe deixa aberto. Ele não pediu autorização para entrar. Entraram dois agentes na casa e um ficou na viatura. Analisando a autodefesa dos acusados – colhidas com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – resta evidente que ambos, a despeito de terem admitido a posse de parte das drogas, os réus negaram a destinação comercial do entorpecente. Ocorre que da versão dos réus emerge-se significativas contradições. O réu Jededias afirmou que não estava com Ademilson e sim com a pessoa de Gabriel e que Ademilson caminhava bem atrás dele. Já Ademilson disse que conhece Jededias no bairro, que estavam sentados juntos numa pedra ao lado do campo, próximo ao gol e que combinaram de usar entorpecentes. E ainda a versão de Ademilson de que deixou escondida um maço com porções de maconha no mato, é absolutamente inconsistente. Ora o réu gastou cerca de R\$140,00 com os entorpecentes e não deixaria a droga longe de si, para fazer uso de uma porção e depois retornar para pegá-los.

Por outro lado, a prova dos autos revela cabalmente a prática do tráfico de drogas, tal como relatada na denúncia.

Com efeito, o Guarda Civil Municipal Julio Gonçalves Machado Queiroz, em sede policial (fls. 13), declarou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estavam em patrulhamento pelo bairro Rosa Garcia 2, quando receberam uma denúncia de um popular anônimo em que informava que pelo pasto da rua Lazaro Phols, local conhecido por tráfico de drogas, havia dois sujeitos, um de nome Jededias, que estava de camiseta amarela, e um outro indivíduo que estava de camiseta vermelha, os quais estariam vendendo drogas. Deslocaram até o local indicado e encontraram dois sujeitos, os quais estavam debaixo de uma árvore. Ao avistarem a aproximação da viatura, ambos saíram rapidamente. Naquela ocasião, viu JEDEDIAS jogando algo ao solo. Eles foram abordados logo em seguida e seu colega de farda Neves realizou a revista pessoal. Com JEDEDIAS, foi localizado 1 pino de cocaína dentro de sua cueca e a quantia de R\$ 20,00. Com o acusado identificado como ADEMILSON, foi localizado em seu bolso 1 porção de maconha e 1 pino de cocaína. Ficou na contenção dos dois e o GCM Neves retornou até o local onde JEDEDIAS jogou algo ao solo, onde foi localizado um maço de cigarro contendo 14 porções de maconha. Indagados, ambos negaram o tráfico de drogas, alegando que haviam adquirido a droga para consumo. Afirmou que JEDEDIAS é conhecido do meio policial por tráfico de drogas e já foi preso por esse delito. ADEMILSON não é conhecido dos meios policiais. Em juízo, disse que estavam em patrulhamento próximo ao bairro Rosa Garcia II, quando um morador os abordou e disse que dois indivíduos estavam fazendo o tráfico, um deles o réu Jededias, passou as vestimentas e o local. Foram ao local apontado, visualizaram os réus próximo a uma árvore, os réus ao avistarem a viatura saíram e Jededias dispensou algo. Com Jededias foi encontrado um pino de cocaína e dinheiro

e ele dispensou uma maço com 14 porções de maconha e com Ademilson uma porção de maconha e uma de cocaína. Os réus disseram que a droga era para uso próprio. Acredita que ambos os réus estavam com aparelhos celulares. Jededias já era conhecido dos meios policiais. O local é conhecido pelo alto índice de comercio de entorpecentes. A abordagem foi por volta das 16 horas e havia outras pessoas no local. Normalmente o usuário pega a mercadoria e sai do local, não ficam ali. Não abordam aleatoriamente, geralmente algum morador faz a denuncia. Não fez abordagem de usuários no local. Depois da abordagem foram para a residência de Jededias, pois ele não estava com documento e informaram sua genitora do acontecido. Não foram a casa de Ademilson, pois acredita que ele estava com documentos. E a casa de Jededias fica próxima ao local em que ele estavam. Tanto ele como o outro GCM ingressaram na residência, mas não houve busca no local.

Convergindo em mesmo sentido, o também Guarda Civil Municipal Fernando Neves dos Santos, em sede policial (fls. 21), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em juízo, disse que estavam em patrulhamento pelo bairro Rosa Garcia, quando foram informados por um individuo de que dois indivíduos de camisetas amarela e vermelha estavam realizando o tráfico num campo. Foram ao local, os réus ao visualizaram a viatura saíram rapidamente e Jededias dispensou algo. Com Jededias foi encontrado um pino de cocaína e dinheiro e o que ele lançou ao solo se tratava de um maço de cigarro com porções de maconha. Com o outro réu havia uma porção de maconha e uma porção de cocaína. O morador indicou os indivíduos, as vestimentas, o nome do Jededias e a localização. Havia pessoas próximas, mas a identificação foi muito precisa e as pessoas que estavam em volta não estavam em contato com os réus. Perguntas da defesa – o local é bem extenso, tem um campo de futebol e uns açudes. Abordaram apenas os réus. Jededias é conhecido dos meios policiais e já o abordou em outras duas vezes. posterior a localização dos entorpecentes, foram com o réu Jededias até sua casa para que ele pegasse seu documento. Ele mora próxima ao local da abordagem. Sua mae estava no local e forneceu o documento do réu. Os réus não aparentavam estar sob efeito de substancia entorpecente e disseram que toda droga encontrada era para uso.

Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas.

Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório.

Neste sentido:

Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu
Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados).

Finalmente, a testemunha Cláudia Aparecida Pinheiro da Silva Santos, em juízo, informou que é mae do réu e foi ouvida sem compromisso. Mora a rua Joao Rodrigues, 54. No dia dos fatos, estava em casa com seu neto e sua filha, tinham acabado de almoçar, o guarda chegou, abriu o portão e disse que precisava entrar para revistar as coisas de Jededias para procurar dinheiro e drogas, perguntou qual seria o

quarto de Jededias. Ele olhou o guarda-roupa, as gavetas, mas não achou nada. Um guarda entrou e o outro ficou na varanda. Acredita que esse guarda que foi em sua casa é o mesmo que o prendeu da outra vez.

Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes.

Ora, é inequívoco que os acusados traziam consigo substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos agentes de segurança, os quais narraram verossimilmente, a apreensão de parte das drogas com os acusados e o restante onde JEDEDIAS dispensou o entorpecente; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 102/104), o qual atestou que as substâncias apreendidas eram entorpecentes.

Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado.

Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida.

Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações e forma de acondicionamento própria para a venda "a varejo" de entorpecentes; 3) a não apreensão de instrumentos utilizados para o consumo da droga; 4) o comportamento suspeito dos acusados consistente em, ao notar a presença dos guardas, dispensar drogas e tentar se evadirem; 5) a exata correspondência entre as circunstâncias geográficas e nominal dos traficantes delatados com as dos acusados; e 6) a existência de mensagens com conteúdo relativo ao exercício da mercancia de drogas no aparelho celular dos acusados (fls. 177/187), em especial: "Tenho 30 em dinheiro e 06 Arica" (fls. 181); "Oq vc vai fazer com 6 arica loco" (fls. 182); e "Se vc me fala q ia precisar de dinheiro nem tinha pegado droga" (fls. 184).

Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte:

"Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaína" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo "ependorf" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da "cocaína" em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de "cocaína" provoca o "enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação" (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato

probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (*praesumptiones hominis*), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, *Elementos de Direito Processual Penal*, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, *Código de Processo Penal Comentado*, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, *Da Prova Penal*, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. *Prova Penal*, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., *verbi gratia*, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588).

Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 102/104) e demonstrado que os réus incorreram em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – trazer consigo –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado.

Certo, portanto, que os réus perpetraram fato típico narrado na denúncia, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o *jus puniendi*, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhes imposta.

I – DO RÉU JEDEDIAS

Observando as circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, vislumbro que as circunstâncias judiciais são favoráveis aos réus. De fato, observo que o apontamento criminal retratado a fls. 47/48 (Proc. 1500373-92.2020.8.26.0571) se refere a ação penal em curso e, a despeito de entendimento pessoal diverso dessa Magistrada, observo que a jurisprudência se consolidou no sentido da imprestabilidade desses registros delitivos como maus antecedentes ou para a valoração negativa em primeira fase (Súmula nº 444 do STJ). Aliás, assim também tem se posicionado a jurisprudência do E. TJSP, apontado que ações penais em curso, ainda que condenações provisória: “embora tal circunstância denote a personalidade desregrada do acusado, não se presta a majorar a sanção inicial, a teor da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.” (TJSP; Apelação Criminal 1502727-43.2020.8.26.0037; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2021; Data de Registro: 03/08/2021). Desse modo fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva, ante à minguia de outras causas modificadoras da pena a incidir.

Cabe ressaltar que, a despeito da admissão da posse das drogas, essa foi acompanhada de alegação de destinação para uso próprio, o que expressa confissão de crime diverso do qual o réu está sendo condenado. E, portanto, não se presta a caracterizar a atenuante de confissão (Súmula nº 630 do C. STJ).

A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, trata-se de réu que está sendo processado em outro feito pelo mesmo delito

que se apura nos autos (fls. 47 – Proc. 1500373-92.2020.8.26.0571), o que é elemento caracterizador de dedicação a atividades criminosas, restando inviabilizada a concessão da benesse em questão.

A propósito, assim se posiciona a jurisprudência do C. STJ: “É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.” (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016).

No mais, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, e, com fulcro no artigo 33, § 3º, c.c. art. 59, III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, considerando sua personalidade criminosa (fls. 47 – Proc. 1500373-92.2020.8.26.0571), bem como pelo histórico infracional de ambos (fls. 49), além da gravidade concreta do delito.

A tão só quantidade de pena aplicada obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e inviabiliza a concessão do sursis.

Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada.

Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos:

“No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena”. (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013).

II – DO RÉU ADEMILSON

Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2.006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. Fixo, portanto, sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, observo que, a despeito do acusado possuir menos de 21 anos quando dos fatos, deixei de aplicar a atenuante de menoridade relativa, já que a pena-base fora fixada no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Mantenho, pois, inalterada sua pena.

Cabe ressaltar que, a despeito da admissão da posse das drogas, essa foi acompanhada de alegação de destinação para uso próprio, o que expressa confissão de crime diverso do qual o réu está sendo condenado. E, portanto, não se presta a caracterizar a atenuante de confissão (Súmula nº 630 do C. STJ).

Na terceira fase, presentes os requisitos legais do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzo a pena em 2/3, patamar máximo em virtude de sua menoridade, aliada a baixa quantidade de drogas apreendidas, indicando que a traficância verificada nos autos foi ato episódico. Nessa esteira, fixa sua pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de outras causas modificadoras da pena a incidir.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento no artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, determino que o réu inicie o cumprimento da pena no regime aberto.

Consigno, por oportuno, que este Juízo, a despeito de considerar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes como delito de gravidade exacerbada, e que merece maior censura penal, modificou o seu entendimento a partir da vigência do artigo 112, § 5º, da Lei nº 7.210/84 – “Lei de Execução Penal” que, expressamente, afastou o caráter hediondo do chamado tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – “Lei de Drogas”).

A despeito da inegável gravidade da conduta do acusado, tem-se que se trata de réu menor, além do que estão presentes os requisitos legais, autorizando a substituição de sua pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em: 1) prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas a serem determinadas

pelo juízo da execução, na razão de uma hora por dia de condenação; e 2) prestação pecuniária, no valor de 01 salário-mínimo, a ser destinada a entidade pública oportunamente especificada pelo Juízo da Execução Penal.

III - DO DISPOSITIVO E DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para, afastando a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas: 1) condenar o réu JEDEDIAS SILVA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal; 2) condenar o réu ADEMILSON ALBERT TEODORO BORGES DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, substituindo-se sua pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em: (a) prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas a serem determinadas pelo juízo da execução, na razão de uma hora por dia de condenação; e (b) prestação pecuniária, no valor de 01 salário-mínimo, a ser destinada a entidade pública oportunamente especificada pelo Juízo da Execução Penal.; e 3) absolver os acusados da imputação de prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu JEDEDIAS, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a prisão provisória do acusado. E mais, trata-se de réu que desde sua adolescência envolvem-se com atividades ilícitas (fls. 49) e que está sendo processado também pela traficância em outro feito (fls. 47 - Proc. 1500373-92.2020.8.26.0571), de modo a revelar que, acaso solto, tornará a delinquir, razão pela qual a manutenção da prisão cautelar de ambos é absolutamente necessária para garantir a ordem pública.

Recomende-se o réu JEDEDIAS na prisão em que se encontra recolhido.

De outro lado, Defiro o Apelo em Liberdade, considerando que o acusado ADEMILSON respondeu ao feito em liberdade (fls. 58/60) e não sobrevieram razões que exigissem sua segregação cautelar. Até porque, substituída sua pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não há mais como se determinar sua segregação cautelar, com espeque no princípio da proporcionalidade. Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta, a pena restritiva de direitos imposta ao réu será convertida em pena privativa de liberdade, com início de cumprimento no regime aberto (art. 44, §§ 4º e 5º, art. 33, § 2º, "c", e § 3º, c.c. art. 59, III, todos do Código Penal, e art.110 da Lei de Execução Penal).

Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento, bem como arquivem-se os autos. Isento o acusado ADEMILSON do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que foi assistido nos autos por defensora dativa (fls. 109).

Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intime-se o réu ADEMILSON para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias.

De outro lado, diante da condenação, fica ainda obrigado o réu JEDEDIAS a recolher custas de 100 (cem) UFESP's, na forma do art.4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Não lhe concedi os benefícios da Justiça Gratuita, pois tal réu constitui advogado (fls. 129), signo presuntivo de riqueza que revela sua capacidade para suportar o ônus financeiro das custas processuais.

Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa e o montante referente às custas processuais. Após, intime-se o réu JEDEDIAS para que efetuem o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei.

Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art.

243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOELHO o pedido confiscatório e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 20,00 em dinheiro - fls. 17) em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminosa.

Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP.

P.R.I.C.

Tatui, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA